

1003958-35.2019.8.26.0220

Classe: Mandado de Segurança Cível

Assunto: Energia Elétrica

Magistrado: FABIO SZNIFER

Comarca: Guaratinguetá

Foro: Foro de Guaratinguetá

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 19/08/2022

... 'o ICMS não é imposto incidente sobre tráfico jurídico, não sendo cobrado, por não haver incidência, pelo fato de celebração de contratos', razão pela qual, no que se refere à contratação de demanda de potência elétrica, 'a só formalização desse tipo de contrato de compra ou fornecimento futuro de energia elétrica não caracteriza circulação de mercadoria'. Afirma-se, assim, que 'o ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Guaratinguetá

Foro de Guaratinguetá

1ª Vara

Av. Dr. Ariberto Pereira da Cunha, 280, Guaratinguetá - SP - cep 12516-410

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1003958-35.2019.8.26.0220 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1003958-35.2019.8.26.0220

Classe - Assunto

Mandado de Segurança Cível - Energia Elétrica

Impetrante:

Posto Clube dos 500 Ltda

Impetrado:

Secretário da Fazenda Pública do Estado de São Paulo

Juiz(a) de Direito: Dr(a). FABIO SZNIFER

Vistos.

Trata-se de mandado de segurança cível impetrado por POSTO CLUBE DOS 500 LTDA, em face de ato do SECRETÁRIO DA FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO, alegando, em síntese, que o impetrado violou seu direito líquido e certo referente à imunidade em relação ao Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços - ICMS, embutido nas contas de fornecimento de energia elétrica, correspondente ao montante total previsto no Contrato de Reserva de Demanda ou Potência, em afronta ao disposto no artigo 155, parágrafo 2º, inciso III, da Constituição Federal. Alega que o ICMS deveria incidir somente sobre o consumo efetivo, e não sobre a demanda em potencial. Assim, requereu o acolhimento do mandado de segurança, para reconhecer o direito de não incidência de ICMS sobre a demanda reservada de potência não utilizada, limitando, portanto, a incidência à energia elétrica efetivamente consumida, com a compensação dos valores recolhidos a maior nos últimos 5 anos e no período posterior ao writ. Emenda à inicial a fls. 400/102, para retificar o valor da causa.

Devidamente notificada, a Fazenda estadual apresentou informações a fls. 412/432, invocando, preliminarmente, a ilegitimidade ativa, a indicação equivocada da autoridade coatora e o não cabimento do Mandado de Segurança. No mérito, alega, em síntese, que toda e qualquer energia consumida depende de prévio ajuste de potência, de modo que a incidência do ICMS é correta, já que houve circulação de mercadoria, e o entendimento diverso contraria o artigo 155, inciso II, da Constituição Federal. Invoca que a base de cálculo é o preço praticado na operação

final, o que envolve a demanda contratada. Requeru a denegação da segurança.

Parecer Ministerial a fls. 450/456, manifestando desinteresse no feito.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

Cabível o imediato julgamento do feito, diante da sua natureza, que exige prova pré-constituída.

Admito o ingresso da FAZENDA no feito, na qualidade de assistente litisconsorcial passivo, nos termos do artigo 7º, inciso II da lei 12.016/09.

Igualmente, diante do comparecimento da Fazenda, fica prejudica a preliminar de inadequação da autoridade coatora, mesmo porque o requerente também indicou no polo passivo a correlação da Secretaria da Fazenda à Procuradoria Geral do Estado. Logo, reputo que preenchido adequadamente o polo passivo, sem qualquer prejuízo à Fazenda Pública.

Diferentemente do sustentado pela autoridade coatora, a impetrante possui legitimidade para discutir a cobrança de ICMS sobre a energia elétrica contratada (e sobre a demanda de reserva de potência), pois irá suportar o ônus tributário e recolher o valor do tributo aos cofres públicos, razão pela qual a regra do artigo 166 do Código Tributário Nacional não tem aplicação na espécie.

A regra contida no artigo 166 do Código Tributário Nacional, por seu turno, incide sobre os chamados impostos indiretos, nos quais ocorre o fenômeno da repercussão, ou seja, é o consumidor final quem arca com os encargos fiscais e não o contribuinte de direito.

Deve ser registrado que a autoridade coatora também é parte legítima, porque é a beneficiária dos valores cobrados a título de ICMS sobre as contas de energia elétrica. A concessionária apenas calcula o valor do tributo sobre a energia contratada e consumida, efetua a cobrança e tem a obrigação de repassar os valores cobrados, mensalmente, à Fazenda do Estado de São Paulo. Neste contexto, rejeito a preliminar suscitada e passo ao exame de mérito. Também nesse sentido:

APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. INEXIGIBILIDADE DE ICMS SOBRE DEMANDA RESERVADA DE ENERGIA. ILEGITIMIDADE ATIVA. O consumidor final possui legitimidade para propor ação declaratória c.c. repetição de indébito para questionar a incidência de ICMS. Entendimento pacificado no STJ. Preliminar rejeitada. DECADÊNCIA OU PRESCRIÇÃO. Aplicação do art. 150, § 1º, CTN e art. 3º da LC 118/2005. Prescrição que passa a contar somente a partir do pagamento antecipado do tributo. Entendimento em consonância com Temas 137 e 138 do e. STJ. MÉRITO. Cobrança de ICMS sobre demanda contratada e não utilizada. Impossibilidade. ICMS que deve incidir apenas sobre a energia elétrica utilizada. Entendimento pacificado do C. STJ (Súmula nº. 391) e pelo C. STF (Tema 176). Precedentes. Sentença mantida. REMESSA NECESSÁRIA E RECURSO DESPROVIDOS. (TJSP; Apelação / Remessa Necessária 0018283-63.2010.8.26.0053; Relator (a): Alves Braga Junior; Órgão Julgador: 6ª Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 9ª Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 31/07/2022; Data de Registro: 31/07/2022; grifo nossos)

Ação declaratória c/c pedido de repetição de indébito. Jundiaí. Preliminares de inadmissibilidade recursal e ilegitimidade ativa afastadas. Mérito. ICMS. Pretensão de afastar a incidência do tributo sobre a demanda contratada, não a consumida, de energia elétrica. Possibilidade. Matéria julgada pelo STJ sob o regime do art. 543-C do CPC e art. 6º da Resolução n. 8/2008. Inteligência da Súmula n. 391 do STJ, Tema 176 do STF e art. 4º, parágrafo único, da Lei Estadual n. 6.374/1989, com a

redação dada pela Lei Estadual n. 16.886/2018. Juros e correção monetária. Aplicação dos Temas 810 do STF e 905 do STJ, além do artigo 167, parágrafo único, do CTN e da Súmula 188 do STJ, com correção monetária pela Tabela Prática do TJSP (IPCA-E). Precedentes. Reexame necessário e recurso da FESP providos em parte, apenas para determinar a aplicação da taxa SELIC após o trânsito em julgado. (TJSP; Apelação / Remessa Necessária 1015121-65.2021.8.26.0309; Relator (a): Antonio Celso Aguiar Cortez; Órgão Julgador: 10ª Câmara de Direito Público; Foro de Jundiaí - Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 22/07/2022; Data de Registro: 22/07/2022; grifo nosso)

A preliminar de inadequação da via eleita se confunde com o mérito, de modo que será decidida definitivamente, conforme teoria da asserção.

A ação mandamental não comporta dilação probatória, exigindo-se, para a sua proposição, a apresentação de prova pré-constituída da liquidez e certeza do direito alegado, conforme entendimento de Celso Agrícola Barbi, verbis: "Enquanto, para as ações em geral, a primeira condição para sentença favorável é a existência da vontade da lei cuja atuação se reclama, no mandado de segurança isto é insuficiente; é preciso não apenas que haja o direito alegado, mas também que ele seja líquido e certo. Se ele existir, mas sem essas características, ensejará o exercício de ação por outros ritos, mas não pelo específico mandado de segurança." (Do mandado de segurança - Celso Agrícola Barbi, 4ª ed. pág.77)

Assim, para o exercício da ação mandamental deve estar presente a demonstração de plano do direito líquido e certo do impetrante. Na espécie, a causa de pedir exposta pela impetrante revela ofensa à direito líquido e certo, consistente na incidência do ICMS somente sobre a energia efetivamente consumida

Nos termos do inciso II, do artigo 155 da Constituição Federal, o fato gerador do ICMS é a operação de circulação de mercadoria, ou a prestação de serviços de telecomunicações e de transporte interestadual ou intermunicipal. A base de cálculo, como regra, é o preço da operação de circulação de mercadoria que, na espécie, é o valor da operação de mercadoria, no caso, da energia efetivamente consumida, sob pena de afronta ao princípio da legalidade.

Aliás, a matéria já está sedimentada, tanto é que já foi sumulada pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça: "O ICMS incide sobre o valor da tarifa de energia elétrica correspondente à demanda de potência efetivamente utilizada" (Súmula 391/STJ).

O C. STJ firmou entendimento no sentido de que a simples formalização de contrato de fornecimento futuro de energia elétrica não caracteriza circulação de mercadoria, razão pela qual não pode o ICMS incidir sobre a denominada "demanda contratada". Em outras palavras, o tributo incide apenas sobre a demanda de potência elétrica efetivamente utilizada pelo consumidor. Nesse sentido o julgamento proferido nos autos do Recurso Especial nº 960.476/SC, sob o regime dos recursos repetitivos:

"TRIBUTÁRIO. ICMS. ENERGIA ELÉTRICA. DEMANDA DE POTÊNCIA. NÃO INCIDÊNCIA SOBRE TARIFA CALCULADA COM BASE EM DEMANDA CONTRATADA E NÃO UTILIZADA. INCIDÊNCIA SOBRE TARIFA CALCULADA COM BASE NA DEMANDA DE POTÊNCIA ELÉTRICA EFETIVAMENTE UTILIZADA. 1. A jurisprudência assentada pelo STJ, a partir do julgamento do Resp 222.810/MG (1ª Turma, Min. José Delgado, DJ de 15.05.2000), é no sentido de que 'o ICMS não é imposto incidente sobre tráfico jurídico, não sendo cobrado, por não haver incidência, pelo fato de celebração de contratos', razão pela qual, no que se refere à contratação de demanda de potência elétrica, 'a só formalização desse tipo de contrato de compra ou fornecimento futuro de energia elétrica não caracteriza circulação de mercadoria'. Afirma-se, assim, que 'o ICMS deve incidir sobre o valor da energia elétrica efetivamente consumida, isto é, a que for entregue ao

consumidor, a que tenha saído da linha de transmissão e entrada no estabelecimento da empresa'. 2. Na linha dessa jurisprudência, é certo que 'não há hipótese de incidência do ICMS sobre o valor do contrato referente à garantia de demanda reservada de potência'. Todavia, nessa mesma linha jurisprudencial, também é certo afirmar, a contrario sensu, que há hipótese de incidência de ICMS sobre a demanda de potência elétrica efetivamente utilizada pelo consumidor. 3. Assim, para efeito de base de cálculo de ICMS (tributo cujo fato gerador supõe o efetivo consumo de energia), o valor da tarifa a ser levado em conta é o correspondente à demanda de potência efetivamente utilizada no período de faturamento, como tal considerada a demanda medida, segundo os métodos de medição a que se refere o art. 2º, XII, da Resolução ANEEL 456/2000, independentemente de ser ela menor, igual ou maior que a demanda contratada. 4. No caso, o pedido deve ser acolhido em parte, para reconhecer indevida a incidência do ICMS sobre o valor correspondente à demanda de potência elétrica contratada mas não utilizada. 5. Recurso especial parcialmente provido. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/08." (Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, j. em 11/03/2009).

Em consonância com referido entendimento, no tema nº 176 de repercussão geral, o E. STF firmou a tese de que a demanda de potência elétrica não é passível, por si só, de incidência de ICMS, na medida em que só integram a base de cálculo do tributo os valores referentes àquelas operações em que haja efetivo consumo de energia elétrica pelo consumidor:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES RELATIVAS À CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SOBRE PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE INTERESTADUAL E INTERMUNICIPAL E DE COMUNICAÇÃO ICMS. ENERGIA ELÉTRICA. BASE DE CÁLCULO. VALOR COBRADO A TÍTULO DE DEMANDA CONTRATADA OU DE POTÊNCIA. (...) 4. Na ótica constitucional, o ICMS deve ser calculado sobre o preço da operação final entre fornecedor e consumidor, não integrando a base de cálculo eventual montante relativo a negócio jurídico consistente na mera disponibilização de demanda de potência não utilizada. 5. Tese: "'A demanda de potência elétrica não é passível, por si só, de tributação via ICMS, porquanto somente integram a base de cálculo desse imposto os valores referentes àquelas operações em que haja efetivo consumo de energia elétrica pelo consumidor'. 6. Recurso extraordinário a que nega provimento." (RE 593.824/SC, Rel. Ministro(a) Edson Fachin)

Portanto, o impetrante tem razão ao entender inexigível o ICMS incidente sobre o valor contratual da demanda reservada de energia elétrica, o que encontra respaldo na jurisprudência consolidada dos tribunais superiores.

Contudo, quanto ao pedido de compensação do indébito recolhido no período quinquenal anterior à propositura, razão não assiste à impetrante, pois o "mandamus" não é ação de cobrança e, assim, deve ser declarado o direito à compensação dos valores indevidamente recolhidos a título de ICMS sobre a diferença entre a energia efetivamente consumida e a "demanda de energia contratada" a partir da impetração, não atingindo o período pretérito.

Nesse sentido, é a Súmula nº 271 do STF: "Concessão de mandado de segurança não produz efeitos patrimoniais em relação a período pretérito, os quais devem ser reclamados administrativamente ou pela via judicial própria."

Igualmente nesse sentido, há jurisprudência do E. TJSP:

TRIBUTÁRIO. ICMS. CARÊNCIA DA AÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. MANDADO DE SEGURANÇA. Inocorrência. Direito líquido e certo amparado que prescinde de dilação probatória. Preliminar rejeitada. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. Energia elétrica. Insurgência contra a incidência sobre a demanda contratada. Tributo que deve incidir apenas sobre a energia efetivamente consumida. Súmula 391 do STJ. Tese fixada pelo E. STF em sede de repercussão geral (Tema 176) no sentido de que "a

demanda de potência elétrica não é passível, por si só, de tributação via ICMS, porquanto somente integram a base de cálculo desse imposto os valores referentes àquelas operações em que haja efetivo consumo de energia elétrica pelo consumidor". COMPENSAÇÃO. Inadmissibilidade. Pretensão à repetição de indébito de ICMS dos últimos cinco anos mediante compensação. A via mandamental não comporta efeitos pretéritos. Súmulas 269 e 271 do STF. Inexistência de lei estadual que autorize a compensação de indébito tributário com lastro em título judicial, nos termos do artigo 170 do CTN. Precedentes. Incidência unicamente da Taxa Selic. Sentença alterada em parte mínima. Recurso do impetrante improvido e recurso da Fazenda do Estado e reexame necessário parcialmente providos. (TJSP; Apelação / Remessa Necessária 1015086-34.2020.8.26.0053; Relator (a): Claudio Augusto Pedrassi; Órgão Julgador: 2ª Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 9ª Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 16/08/2022; Data de Registro: 16/08/2022; grifo nosso)

Finalmente, considerando que o pedido abrange restituição de indébito tributário incidente após a impetração, aplicável o Tema 188 do STJ, ou seja, IPCA-E dos descontos até o trânsito, e SELIC após o trânsito em julgado.

Ante o exposto, CONCEDO EM PARTE A SEGURANÇA para reconhecer a não incidência de ICMS concernente ao fornecimento de energia elétrica sobre a demanda reservada de potência não efetivamente utilizada/consumida; e assegurar a restituição do indébito tributário, desde a impetração, mediante compensação, cujos valores serão corrigidos monetariamente pelo IPCA-E do desembolso até o trânsito em julgado, e, após, exclusivamente pela taxa SELIC.

Custas nos termos da lei, pelo impetrado, observada sua isenção. Sem honorários (artigo 25 da Lei 12.016/09, Súmula 105/STJ e 512/STF).

Decorrido o prazo para a interposição de recurso voluntário, ao Reexame Necessário, conforme artigo 14, parágrafo 1º da lei 12.016/09.

Oficie-se à D. Autoridade impetrada, para cumprimento, e à pessoa jurídica interessada, comunicando-se a decisão, na forma do art. 13 da Lei 12.016/09.

Oportunamente, arquivem-se os autos observadas as formalidades legais.

P.R.I.

Guaratinguetá, 19 de agosto de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA